خصوصيات الإجراءات في مسطرة التحفيظ العقاري

الدكتور عمر أزوكار
محام بهيئة البيضاء

مقدمـــــة :

تجدر الإشارة في البداية إلى أنه يجب التمييز بين خصوصيات الإجراءات في قضايا التحفيظ، وخصائص التحفيظ، ذلك أن الخصوصيات تظهر بجلاء في إطار مميزات المسطرة في قضايا التحفيظ عن باقي القضايا المتعلقة بالعقار غير المحفظ، كما أنه في إطارها تتماسك الإجراءات الشكلية مع الموضوعية لتقرير الحقوق، بحيث لا يمكن فصل الشكل فيها عن الموضوع فيكمل أحدهما الآخر. أما الخصائص المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري، فيقصد بها أساسا مجموعة المميزات التي تخصه وتميزه عن باقي فروع القانون.

ولعل أهمية الخصوصيات في مجال إجراءات مسطرة التحفيظ العقاري، تكمن في الأرضية الصلبة التي يشكل دعامتها المبادئ الأساسية في قانون التحفيظ والتي تحكم بدورها إقرار الحقوق أو إنشاؤها أو إلغائها أو تعديلها فقط، مما يؤهله لضمان الاستقرار وثقة المتعاملين في العقار.

وإذا كان ظهير 9 رمضان 1331 هو المطبق من حيث المسطرة لإخضاع العقار المحفظ للتشريع المحدد في ظهير 2 يونيو 1915، فإن ذلك يعني الخروج عن القواعد العامة المحددة في قانون المسطرة المدنية، وبالتالي ضرورة رصد الخصوصيات المسطرية في قضايا التحفيظ العقاري من خلال الوقوف عن الاختلاف الموجود بين نظام التحفيظ العقاري والقواعد العامة، سواء تعلق الأمر بجانب الشكل أو الموضوع.

وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين، نخصص الأول لخصوصيات المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، أما الثاني فسنعرض فيه لهذه الخصوصيات في إطار المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ.

المبحث الأول: خصوصيات المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ

تتسم المسطرة المؤدية إلى إنشاء الرسم العقاري بالازدواجية، فهي إدارية يسيرها المحافظ منذ تقديم المطلب إلى حين تأسيس الرسم العقاري، وقضائية حينما يحال مطلب التحفيظ على القضاء للبت في التعرضات. وهذا معناه أن مسطرة التحفيظ في الأصل إدارية، لكن قد تتخللها تعرضات على مطلب التحفيظ فتتحول إلى مسطرة قضائية، بخلاف بعض الأنظمة القانونية المقارنة، كالنظام السوري واللبناني، حيث المسطرة قضائية أصلا، أي أن تحفيظ العقار يتم بقرار يصدر عن القضاء الذي يعود إليه أمر البت في جميع ما يمكن أن يحصل أثناء مسطرة التحفيظ، من تدخلات أو تعرضات يثيرها الغير.

وهكذا فإن تناول هذا المبحث يقتضي تقسيمه إلى مطلبين، نعالج في الأول الخصوصيات المتعلقة بمطلب التحفيظ، ونعرض في الثاني للخصوصيات المتعلقة بالتعرض.

المطلب الأول: خصوصيات تتعلق بتقديم مطلب التحفيظ

إن التحفيظ العقاري يتسم بطابع اختياري حسبما أكده الفصل 6 من قانون التحفيظ العقاري[1]، فكل مالك عقار أو صاحب حق عيني عقاري يستطيع إذا أراد أن يتقدم بمطلب بالتحفيظ بهدف جعل عقاره أو الحق العيني الذي يملكه تابعا إلى نظام السجل العقاري، والاستفادة من هذا النظام، اما إذا

---

[1] – ينص الفصل 6 أعلاه على أن : " التحفيظ أمر اختياري. غير أنه إذا قدم طلب التحفيظ، فإنه لا يمكن سحبه مطلقا ". وهذا يعني أن المشرع بين الهدف من وراء عملية التحفيظ حتى لا يصبح وسيلة للتلاعب والتردد بين الأفراد. ولقد تم إدخال هذه المادة ضمن ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى ظهير 25 غشت 1954.

لم يرغب في تقديم هذا المطلب، فلا وجود لأية وسيلة لإرغامه على ذلك، علما أن هذا الاختيار مخول فقط لصاحب العقار غير المحفظ، أما العقار المحفظ فلا يمكن إخراجه من هذا النظام[1].

الفقرة الأولى: المتعرض هو الذي يقع عبء الإثبات

تبدأ المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ بإيداع مطلب التحفيظ لدى مصلحة المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها الترابي العقار المطلوب تحفيظه[2]، مرفقا بالوثائق والحجج المؤيدة للحق المراد تثبيته، مع أداء المصاريف ورسوم التسجيل اللازمة قانونا. وتصبح بالتالي وضعية العقار القانونية خاضعة لأحكام ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري. كما أن العقار في طور التحفيظ يبقى في هذه المرحلة خاضعا من حيث الموضوع لقواعد الشريعة الإسلامية، والفقه المالكي على الخصوص ما عدا مسألة جعل المتعرض في مركز المدعي، وطالب التحفيظ في مركز المدعى عليه التي تستشف صراحة من خلال مقتضيات الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري[3].

ذلك أن العمل القضائي قد استخلص من مقتضيات الفصل 37 أعلاه أن محكمة التحفيظ لا يمكنها البت في إلا في حدود ادعاءات المتعرضين في مواجهة

---

[1] – الدكتور زيد قدري : " مدى إلزامية التحفيظ العقاري " منشور بندوة "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب"، غشت 1992، ص 21.

[2] – ويجب أن يقدم المطلب من قبل الأشخاص الوارد ذكرهم حصرا في الفصل 10 من ظهير 9 رمضان.

[3] – كان النص الأصلي لسنة 1913 يخول للمحكمة صلاحية النظر في مطلب التحفيظ استنادا لمقتضيات الفصل 38 الذي كان ينص على أنه: " إذا قضى الحكم الصادر برفض مطلب التحفيظ كلية فإنه يتعين فقط إعادة الأطراف التي كانوا عليها من قبل ". إلا أنه التعديل التشريعي الذي جاء بتاريخ 24 شتنبر 1917 جرد محكمة التحفيظ من البت في مطلب التحفيظ وقصر اختصاصها على النظر في التعرضات.

مطلب التحفيظ، وليس من اختصاصها النظر في مزاعم طالب التحفيظ لأن ذلك يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات المحافظ العقاري وحده، كما أنه ليس من اختصاصها البت في في حقوق المتعرضين في مواجهة بعضهم البعض[1]. هذا بالإضافة إلى اعتبار المتعرض مدعيا يقع على عبء إثبات مؤيدات تعرضه[2]، أما طالب التحفيظ فيأخذ وضعية المدعى عليه، ويعفى مبدئيا من كل إثبات، ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في أحقيته للملك، أو في سبب تملكه، خاصة إذا

---

[1] – جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 181 بتاريخ 1959/04/29 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 24 السنة الثالثة دجنبر 1959 ص 342 الذي جاء فيه : " أن قضاة الموضوع لا يملكون في قضايا التحفيظ الفصل بين المتعرضين، بل لهم أن ينظروا خاصة بين هؤلاء وطالبي التحفيظ".

ومؤدى هذا التوجه أن الحكم الصادر في قضايا التحفيظ العقاري لا يكتسب حجية الشيء المقضي به فيما بين المتعرضين. وأنه يمكن الحكم بصحة عدة تعرضات ضد مطلب تحفيظ واحد، هذا فضلا عن كون المتعرض الذي حكم بصحة تعرضه ابتدائيا لا يمكنه استئناف الحكم ضد متعرض آخر حكم بصحة تعرضه ما دام طالب التحفيظ لم يستأنف هذا الحكم.

[2] – جاء في حكم ابتدائي صادر بتاريخ 2010/07/15 ملف 2009/10/75 غير منشور ما يلي:

"... وحيث باطلاع المحكمة على مضمون الرسم المذكور ثبت لها أنه تضمن الإشارة إلى أن شهوده شهدوا بخصوص المدة أنها تزيد عن أمد الحيازة المعتبرة شرعا.

وحيث من الثابت فقها أن الإجمال في بيان مدة الحيازة يعد عيبا في البينة الشاهدة بها، وهذا ما أكده المجلس الأعلى حينما اعتبر أن : " الإجمال في بيان مدة الحيازة، واقتصار الشهود على القول بأنها تزيد على أمد الحيازة المعتبرة شرعا يعد عيبا في الرسم ". (قرار صادر بتاريخ 1985/5/8 تحت عدد 110 في الملف المدني 72015 – منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى – عدد 38/37 – ص 60).

وحيث بذلك، فإن الإجمال في مدة الحيازة مبطل للشهادة بها لما في المعيار عن اليزناسي : " أن المذهب رد الشهادة بالإجمال والإرسال".

وحيث في ملف النازلة فإن ذكر الشهود للمدة بالإجمال يعد عيبا في رسم الاستمرار المعتمد في التعرض، ويجعله بالتالي ناقصا عن درجة الاعتبار شرعا، ويكون التعرض المذكور حريا بالتصريح بعدم صحة تعرضه، وتحميل المتعرض صائره ".

كان حائزا للعقار موضوع مطلب التحفيظ، إذ يفترض فيه أنه المالك لكونه يحوز العقار، ويتوفر على صفة طالب التحفيظ[1].

وقد أكد المجلس الأعلى ذلك حينما اعتبر "أن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه مركز المدعي عليه، ولا يجب عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية"[2]. غير أن المجلس الأعلى قد خالف ذلك الاتجاه معتبرا أن: "نظر قاضي التحفيظ يقتصر على البت في الحقوق المدعى بها من قبل المتعرضين، وعند عدم اقتناعه بوجود تلك الحقوق لا يكون مؤهلا للبت في الحجج المؤيد بها طلب التحفيظ الذي يتخذ المحافظ في شأنه ما يراه مناسبا "[3].

ويظهر جليا أن هذه القاعدة الواردة في الفصل 37 أعلاه والتي كرسها العمل القضائي لمحاكم الموضوع[4]، تخالف الأحكام العامة التي تقضي بقيام قرينة الملكية لصالح حائز العقار، فالحائز يفترض فيه أنه المالك، لذلك يجب على

---

[1] – د. محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغرب، طبعة دار الثقافة الجديدة، البيضاء، ص 209.

[2] – قرار صادر بتاريخ 20 مارس 1963، ملف مدني عدد 165 – قضاء المجلس الأعلى عدد 1 أكتوبر 1968، ص 24.

[3] – قرار عدد بتاريخ 1976/07/16 منشور بمجلة المحاماة عدد 13 أكتوبر 1978 ص 131.

[4] – جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2010/06/10 ملف رقم 2010/10/10 غير منشور ما يلي:

"... وحيث من المستقر عليه قضاء أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري، توحي أن المتعرض هو الذي يعتبر طرفا مدعيا وبالتالي يقع عليه عبء الإثبات.

... وحيث في ملف النازلة فإن رسم الاستمرار المستدل به من طرف المتعرض لا يتوفر على شروط الملك، لأنه أشار فقط إلى أربع شروط وهي اليد والطول والنسبة وعدم التفويت، دون ذكره لعدم المنازع أو المعارض، مما يجعل رسم الاستمرار المذكور غير عامل، وناقص عن درجة الاعتبار شرعا، ويكون بالتالي تعرض المتعرض حريا بالتصريح بعدم صحة تعرضه، وتحميله صائره ".

الخصم أن يدحض هذه القرينة ويقدم البينة المعاكسة، أما اعتماد الأسبقية في تقديم مطلب التحفيظ لتحديد مركز طلب التحفيظ والمتعرض، يتعارض مع أحكام الفقه المالكي[1].

الفقرة الثانية: مسطرتا الخلاصة الإصلاحية والإيداع

جدير بالذكر أن تقديم مطلب التحفيظ لا يمنع من التصرف فيه، بل يمكن إجراء كافة التصرفات على العقار في طور التحفيظ وترتيب مختلف التكاليف عليه، إلا أنه يتعين إيداع كل العقود المتعلقة بهذه التصرفات والتكاليف لدى مصلحة المحافظة العقارية من قبل المستفيدين من تلك التصرفات، إما طبقا لمسطرة الخلاصة الإصلاحية المنصوص عليها في الفصل83، أو مسطرة الإيداع الواردة في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري.

وفي هذا الإطار ميز بعض الفقه بين التصرفات والتكاليف الجارية على العقار في طور التحفيظ.

---

[1] – يذهب الأستاذ روش في تعليق له بأن " الإجتهاد القضائي قد تبنى هذه القاعدة بصورة لا منطقية ذلك أن عبئ الإثبات مسألة موضوع، وقد استقر العمل على أن جوهر الحق في قضايا العقار في طور التحفيظ يبقى خاضعا لقواعد الشريعة الإسلامية. وأن قواعد الفقه الإسلامي هي الواجبة التطبيق في الموضوع. بالرجوع إلى هذه القواعد نجد أن قرينة الملكية تلعب لفائدة من بيده الحيازة. ويرى الأستاذ روش بأن صفة المدعي المعطاة للمتعرض صفة مصطنعة مردها قاعدة شكلية تستند إلى أن المتعرض بتعرضه ضد مطلب التحفيظ يعطي ميلادا للنزاع، وأن هذه القاعدة ليس لها أي سند قانوني".

– أشار إلى هذا التعليق : ذ شعيب محمد ناجي : مقال بعنوان : " صلاحية محكمة التحفيظ للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات " – منشور بمجلة التحفيظ العقاري – عدد 4 – يونيو 1993 – ص 10.

ذلك أن انتقال العقار جزءا أو كلا نتيجة تصرف ما سواء بعوض أو بغيره، يستلزم من المتصرف إليه كي يثبت له حقه يوم صدور قرار بالتحفيظ اتباع أحد الطريقتين طبقا لما جاء في الفصلين 83 و84 من ظهير التحفيظ، فإما أن يقوم المتصرف إليه بإيداع صك التصرف في المحافظة العقارية، وتسجيل هذا الإيداع في سجل التعرضات. ذلك أن صدور تصرف من المتصرف بقبول مضمون تعرض المتصرف إليه، عندما يبادر المحافظ إلى قيد العقار كله أو بعضه على اسم المتصرف إليه في الرسم العقاري يوم اتخاذ قرار التحفيظ.

كما يمكن للمتصرف إليه أن يقوم بإيداع العقد في المحافظة مشفوعا بطلب تصحيح لطلب التحفيظ الأصلي، ويطلب فيه متابعة مسطرة التحفيظ باسمه وحده أو باسمه واسم طالب التحفيظ الأصلي معا.

ومؤدى ذلك، أنه يحق لصاحب الحق المنشأ أو المعدل أو المغير أن يطلب من المحافظ – أثناء جريان المسطرة – العمل على إحلاله محل طالب التحفيظ في كافة حقوقه أو في بعضها فقط وذلك عن طريق النشر بالجريدة الرسمية. فإذا حل محل طالب التحفيظ بالنسبة لكافة العقار، فإن اسم طالب التحفيظ يختفي بصفة نهائية بمجرد نشر الخلاصة الإصلاحية بالجريدة الرسمية لكون الرسم العقاري سوف يؤسس في اسم من انتقل إليه الحق بصفته خلفا خاصا.

أما فيما يتعلق بالتكاليف فيمكن اثنان جريان مسطرة التحفيظ إيقاع رهن رسمي على عقار في طور التحفيظ، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للعقارات الغير المحفظة والتي لا تقبل الرهن الرسمي، وتفسير ذلك أن العقار في طور التحفيظ أضحى يتمتع بنوع من العلانية، الشيء الذي يجعل الرهن الرسمي سار بالحق الغير رغم عدم تخلي الراهن عن حيازة العقار المرهون، ولكن يتحتم

على المرتهن إيداع سند الرهن في محافظة الملكية العقارية ليتأتى تسجيله في السجل العقاري يوم صدور القرار القاضي بتحفيظ العقار على اسم مالكه وتسليم المرتهن شهادة بوقوع هذا التسجيل.

وحسب مقتضيات الفصل 204 من ظهير 2 يونيو 1915، فإذا تم تحفيظ العقار، وسجل الرهن أصولا في السجل العقاري، فإن نزع الملكية للعقار المرهون يجري بالاستناد إلى الشهادة الممنوحة للدائن المرتهن، لأن مثل هذه الشهادة (الممنوحة للدائن المرتهن) تعتبر بمثابة سند تنفيذي. في حين إذا كانت مسطرة التحفيظ لم تنته بعد، فإن الدائن المرتهن لا يحق له نزع ملكية العقار المرهون من أجل استيفاء دينه، إلا بعد حصوله على قرار قضائي ببيع العقار بالمزاد العلني[1].

المطلب الثاني: خصوصيات تتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ

لا يعني إيداع مطلب التحفيظ إيذانا بالسير في المسطرة الإدارية إلى النهاية، بل لابد وأن يحصل تعرض غالبا على هذا المطلب لتتحول المسطرة إذ ذاك على رحاب القضاء قصد الفصل، في ما يدعيه المتعرض سواء كان تعرضا كليا أو جزئيا أو على مجرد الحدود أو أحد الحقوق العينية.

---

[1] – جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير في الملف عدد 07/12/12 تحت رقم 27 بتاريخ 2007/03/22 منشور بمنشورات مجلة الحقوق المغربية – العمل القضائي في نزاعات التحفيظ العقاري – العدد 1 – سنة 2099 – ص 61 ما يلي:

" إن مجرد وضع مطلب تحفيظ قطعة أرضية لا يفيد تملك طالب التحفيظ لها وتبقى خاضعة لأحكام الفقة الإسلامي ما لم يتم تأسيس الرسم العقاري.

إن إيداع الرهن بمطلب التحفيظ في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري يعطي لصاحبه إمكانية ترتيب هذا الحق في التسجيل والتمسك به في مواجهة الغير على أن يسجل هذا الحق في الرسم العقاري يوم التحفيظ ".

والتعرض على مطلب التحفيظ له مسطرته الخاصة التي تميزه سواء من حيث الأطراف، أو من حيث الإجراءات.

الفقرة الأولى: أطراف النزاع في التعرض

إن التعرض على مطلب التحفيظ لا يثبت لأي كان، وإنما لأصحاب الحقوق العينية دون الشخصية، أي لأصحاب الحقوق الخاضعة للتحفيظ العقاري، ويمكن تسجيلها في الرسوم العقارية (ف 65 من ظهير التحفيظ) [1]، أي أن التعرض في مجال العقار في طور التحفيظ يكون ضد مطلب تحفيظ ولإثبات أحد الحقوق العينية كما هي منصوص عليها على سبيل الحصر ضمن التعداد الوارد في الفصل 8 من ظهير 2 يونيو 1915. كما أن الفصل 14 من ظ ت ع المعدل بظهير 25 غشت 1954 لم يضع أية قيود أو موانع في مواجهة الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة التعرض، لأن صيغته التشريعية جاءت عامة من خلال النص على " أنه يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ ". وهكذا فإن المشرع توخى عد التعسف في استعمال حق التعرض من خلال حصر مجال إعماله فيما يلي:

- حالة التزاع بشأن حق ملكية العقار موضوع التحفيظ كليا أو جزئيا.
- حالة التزاع بشأن مدى حق الملكية كما لو تعلق الأمر بعقار مشترك على الشياع.

---

[1] – يلاحظ أن الفصل 14 من ظهير التحفيظ المعدل بظهير 25 غشت 1954، لم يضع أي قيد في مواجهة الأشخاص الذين يريدون ممارسة حق التعرض، فجاءت عبارة النص عامة "يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ" إلا أنه لا يمكن التعرض إلا ممن يدعي حقوقا قابلة للتحفيظ والتسجيل. د. محمد خيري، م.س، ص 169.

- حالة النزاع بشأن حدود العقار.
- حالة الادعاء بمباشرة حق من الحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل، كما لو فوت طالب التحفيظ أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية أو أثقله بأحد الحقوق العينية التبعية ثم حصل نزاع بشأن تلك الحقوق أثناء سريان مسطرة التحفيظ.

الفقرة الثانية: خصوصية الإجراءات في التعرض

يقدم التعرض على مطلب التحفيظ وجوبا إلى المحافظ العقاري أو قاضي التوثيق او القائد قبل انصرام أجل شهرين ابتداء من نشر الإعلان بانتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية. كما يباشر التعرض على مطلب التحفيظ على وجه الاستثناء خارج أجل شهرين طبقا للفصل 29 من ظهير التحفيظ، وشريطة وجود مبرر لذلك. وأن هذا النوع من التعرض يمكن تقديمه أمام المحافظ متى كان الملف لازال بين يديه في مرحلته الإدارية، أو أمام وكيل الملك إذا تمت إحالة الملف على المحكمة للبت في التعرضات، مع العلم أن إعمال الفصل 29 أعلاه أمام المحافظ يستلزم وجود تعرضات عادية سابقة[1].

---

[1] – تجدر الإشارة إلى إشكالية تداخل الاختصاص بين وكيل الملك والمحافظ العقاري حول فتح التعرض الاستثنائي الوارد في الفصل 29 أعلاه الذي ينص على ما يلي: "بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ مادام لم يوجه الملف إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية وكذا بعد توجيهه إذا اتخذ وكيل الدولة قرارا بذلك.

إن طلب قبول التعرض في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة يمكن أن يحرر في رسالة عادية وتبلغ هذه لطالب التحفيظ والأشخاص الآخرين المعنيين بالأمر على يد المحافظ أو وكيل الدولة لدى المحكمة التي رفعت إليها القضية ويمكن لكل منهما أن يستمع أو يعمل على الاستماع إلى الأطراف قبل إن يبت في الأمر ولكل منهما نفس الصلاحيات في هذا الشأن".

واستنادا إلى هذا الفصل، يجوز لكل شخص فاته الأجل القانوني دون تقديم تعرضه داخل الأجل المحدد في الفصل 24 المشار إليه أن يوجه رسالة عادية إلى السيد المحافظ العقاري إذا كان

=الملف لا زال في مرحلته الإدارية وإلى السيد وكيل الملك إذا أحيل الملف إلى القضاء، حيث يطلب فيه قبول تعرضه، وحينئذ تبلغ هذه الرسالة لطالب التحفيظ وللمتعرضين الآخرين وبعد أن يستمع المحافظ أو وكيل الملك إلى الأطراف يتخذ قرارا أما بقبول التعرض أو برفضه وفقا لسلطتهما التقديرية.

ومع ذلك، فإن الإشكال يطرح بشأن حدود الاختصاص بين المحافظ ووكيل الملك للبت في طلب التعرض خارج الأجل بالقبول أو الرفض، ومدى إمكانية رقابة القضاء الإداري على قرار السيد المحافظ المتخذ في موضوع التعرض خارج الأجل.

وجوابا على ذلك نورد ما جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ما يلي: "في الاختصاص: حيث إن الدعوى ترمي إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار عدد92/5/5933 الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 25شتنبر1992 القاضي بفتح أجل جديد لتعرض المطلوب في الطعن على مطلبي التحفيظ عدد 35855/م وعدد 35856/م.

وحيث أثار هذا الأخير الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية على أساس أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالبت في صحة فتح أجل التعرض من عدمه.

لكن حيث إن التعرضات تقدم في الأصل إلى المحافظة العقارية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة لتلقيها واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها، وحتى إذا قدمت إلى وكيل الملك في إطار الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن هذا الأخير بعد قبول فتح أجل جديد لها يخبر بذلك المحافظ العقاري قصد تسجيلها واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنها، ومن تم فإن القرارات التي يتخذها وكيل الملك في إطار الفصل المذكور إنما هي قرارات إدارية محضة تدخل في زمرة التدابير الإدارية التي تتخذها النيابة العامة خارج اختصاصاتها القضائية المحددة بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مما يكون معه الاختصاص النوعي بالبت في طلبات إلغائها منعقدا للمحكمة الإدارية. في الشكل:حيث إن عريضة الطعن قدمت من ذي صفة ومصلحة داخل الأجل القانوني مادام أنه ليس بالملف ما يثبت. وفي الموضوع:حيث أسس الطعن على عدة وسائل من بينها مخالفة القرار المطلوب إلغاؤه للقانون حسبما هو مفصل بعريضة الطعن أعلاه. وحيث إن مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري تقضي أن أجل التعرضات يبتدئ بفتح مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية وينتهي بمرور شهرين على نشر إعلان انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية وبعد انصرام هذا الأجل، فإن المادة 29 من نفس الظهير نصت على إمكانية قبول التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ العقاري ما دام ملف التحفيظ لم يوجه إلى المحكمة الابتدائية، وكذا بعد توجيه إذا اتخذ وكيل الملك إلى النظر حيث تكون له صلاحية قبول أو رفض طلب التعرض خارج الأجل، أما بعد إحالة الملف على القضاء للبت في تعرضات الواردة على مطلب التحفيظ وطيلة الفترة التي تستغرقها المسطرة القضائية، فإن لوكيل الملك الحق في اتخاذ قرار بفتح أجل جديد للتعرض إلى غاية انتهاء المسطرة القضائية، وبعدها لا يسمح لأي منهما لا للمحافظ ووكيل للملك – أن يقبل تعرضات جديدة.

وهكذا يلاحظ أن مسطرة التحفيظ تكون إدارية في الأصل، إلا أنه قد يحصل تعرض ضد مطلب التحفيظ، فتتوقف إجراءات عملية التحفيظ إلى أن يتم الفصل في أحقية وصحة التعرض بحكم مكتسب لقوة للشيء المقضي به بين الطرف المتعرض وطالب التحفيظ، أو إنهاء النزاع بينهما بطريقة ودية من خلال لجوئهما إلى الصلح أمام المحافظ الذي يبرم عقدا بينهما وتكون له قوة العقد العرفي.

المبحث الثاني: خصوصيات المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ

يحيل المحافظ ملف التحفيظ برمته إلى المحكمة الابتدائية للفصل في التعرضات المثارة ضد مطلب التحفيظ، سواء ما تعلق منها بمطلب التحفيظ، أو قرارات السيد المحافظ، فما هي الخصوصيات التي تتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ في جميع مراحل التقاضي، وما هي خصوصيات الطعن في قرارات السيد المحافظ؟.

=وحيث ثبت من وثائق الملف أن مطلبي التحفيظ عدد 35855/م و 35856/م اللذين تقدم بهما موروث الطاعنين قد تم =البت في التعرضات المقدمة بشأنهما بمقتضى الحكم رقم 90/2 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 26فبراير1990 في الملف عدد 88/6 الذي قضى بتسجيل الصلح الواقع بين الأطراف وبإرجاع الملف برمته إلى المحافظ على الأملاك العقارية وأنه بتاريخ 25 شتنبر1992 أصدر وكيل الملك قراره المطعون فيه بفتح أجل جديد لقبول تعرض المطلوب في الطعن على المطلبين المذكورين.

وحيث إن المقرر الذي اتخذه وكيل الملك بفتح أجل جديد للتعرض بعد صدور الحكم المذكور على إثر التعرضات المقدمة بشأن مطلبي التحفيظ المعنيين بالأمر، إنما هو قرار مخالف لنص الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري الذي قيد صلاحية وكيل الملك لفتح أجل جديد للتعرض بالحالة التي يكون فيها الملف رائجا أمام القضاء وأن المسطرة القضائية قد انتهت بصدور الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه، فإن وكيل الملك لم يعد مختصا لإلغاء مقرر بفتح أجل للتعرض، الشيء الذي يكون معه القرار المطعون فيه متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون ومعرضا بالتالي للإلغاء".

- حكم المحكمة الإدارية صادر بتاريخ 19 شتنبر2005 ملف رقم: 2005/3/58غ – منشور بمجلة محاكم مراكش – العدد 1 – سنة مارس 2007 – ص 337.

المطلب الأول: الخصوصيات المتعلقة بالبت في التعرض

إن ملف النزاع والذي يتعلق بمطلب تحفيظ عقار ما، ورد عليه تعرض، غالبا ما يندرج بين المحكمة الابتدائية، الاستئنافية وصولا إلى المجلس الأعلى فكل درجة من درجات التقاضي تتميز بخصوصيات معينة.

الفقرة الأولى: الإجراءات أمام المرحلة الابتدائية

أعطى المشرع المغربي للمحاكم الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا إلا ما استثني بنص خاص، ما عدا إذا تعلق الأمر بقضايا العقار في طور التحفيظ، فإنه يتعين تطبيق النص الخاص عند تعارضه مع النص العام.

وهكذا، فإن مسطرة التحفيظ تتميز بعدة خصوصيات من ضمنها:

1- المسطرة الشفوية: لما كان الأصل في مسطرة التحفيظ هو كونها إدارية يتولاها المحافظ، مما يعني أن كل ما يتعلق بمطلب التحفيظ والتعرض ينظر فيهما بالدرجة الأولى المحافظ. وفي حالة تعذر رفع التعرض عن طريق الصلح فإنه يرفع الأمر إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، وتعد هذه الميزة الإجرائية الأولى، حيث ان المسطرة العادية تقتضي تقديم المقال الافتتاحي شخصيا إلى المحكمة الابتدائية من طرف من له الصفة والمصلحة والأهلية في دعوى معينة او بواسطة من ينوب عنه.

وعليه فإن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يتقدم بتعرضه إلى المحافظ العقاري، وهذا الأخير هو الذي يتولى المقال وتهييئ الملف ثم يحيله إلى المحكمة الابتدائية المختصة[1]، وهو خلاف القواعد العامة الواردة في الفصل 31 م.م.

---

[1] د. محمد خيري: " خصوصيات قضايا التحفيظ " - مقال منشور بندوة العقار المحلية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، ص 237.

2- **الرسوم القضائية**: تؤدى الرسوم القضائية المتعلقة بالتحفيظ مسبقا أمام المحافظة العقارية منذ التعديل الذي تم بمقتضى ظهير 25 غشت 1954، ولا تؤدى أمام كتابة الضبط للمحكمة، بخلاف المسطرة العادية، حيث تؤدى الرسوم القضائية أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة عند إيداع المقال بصندوق المحكمة.

3- **مسطرة القاضي المقرر**: إن قضايا التحفيظ العقاري تتميز بوجود قاضي مقرر تختلف مهامه عن مهام القاضي العادي، ذلك أن ظهير التحفيظ العقاري قد نص مسطرة خاصة لتجهيز ملفات التحفيظ العقاري، ولم يحل بشأنه على قانون المسطرة المدنية باعتباره مرجعا عاما في الإجراءات المسطرية[1].

وبالرجوع إلى الفصل 32 من ظهير ت ع، يتضح أن تعيين القاضي المقرر يعتبر من إحدى خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري على الرغم من أن المحاكم لا تعير أي اهتمام للتمييز بين مفهومي القاضي المكلف الذي يعنى بالقضايا العادية والقاضي الذي يبت في قضايا التحفيظ[2].

4- **استدعاء الأطراف**: فيما يتعلق بانعقاد الجلسات فإن القضايا العقارية تتميز بكون حضور الأطراف فيها غير إلزامي، لأن الحكم يكون دائما علنيا وحضوريا وابتدائيا، وهذا ما يفسر كون الأحكام الابتدائية لا تقبل التعرض وتكون دائما ابتدائية مهما كانت قيمة النزاع ولو لم تتجاوز 3000 درهم.

---

[1] - يشبه الأستاذ محمد خيري دور القاضي المقرر بدور قاضي التحقيق، ما دام له حق اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي تمكن المحكمة من البت في القضية. ويلاحظ أن تعيين القاضي المقرر إنما هو لمصلحة المتقاضين، وكذا خدمة العدالة، إلا أن الواقع العملي غالبا ما يكشف عن غياب هذه الاعتبارات، وذلك حينما ينيب القاضي المقرر عنه، إما خبيرا، أو مهندسا، لأن هؤلاء لا يتوفرون على الخبرة القانونية الكافية للإحاطة بالموضوع بشكل مفيد للقضية.

[2] - د. محمد خيري، خصوصيات قضايا التحفيظ، م.س، ص 238.

5- **التبليغ التلقائي**: تتميز المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ العقاري بكون التبليغ يجب أن يتم بالموطن المختار[1] داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الحكم عملا بمقتضيات الفصل 40 من ظ ت ع. ويتعين الإشارة في التبليغ إلى أنه بالإمكان الطعن بالاستئناف داخل الأجل المقرر في الفصل 134 من ق م م الجديد الحال محل الفصل 226 من ق م م القديم تحت طائلة البطلان[2]، علما أن هذا التبليغ لم يحدد له المشرع أي شكل و لم تتم الإحالة بشأنه على قانون المسطرة المدنية حسبما أكده المجلس الأعلى[3]. وأن التبليغ التلقائي هو إجراء إلزامي[4] يترتب عن مخالفته اعتبار التبليغ المختار للأحكام الصادرة في مادة التحفيظ غير قانوني ولا يترتب عنه أي أثر[5].

---

[1] – قرار المجلس الأعلى عدد 231 بتاريخ 1968/05/15 منشور بمجلة قضاء الملجلس الأعلى عدد 2 ص 27.

[2] – قرار المجلس الأعلى عدد 911 الصادر بتاريخ 1998/02/11 ملف مدني رقم 1993/3036 منشور بمؤلف المجلس الأعلى – م س – ص 53.

[3] - قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1977/10/27 منشور بمجلة القضاء والقانون – عدد 128.

[4] – جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 630 صادر بتاريخ 1989/3/1 ملف مدني رقم 1983/4668 منشور بمؤلف المجلس الأعلى تحت عنوان: " مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى " – طبعة 2009 ص 52 ما يلي:

" .. إن مقتضيات الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري التي تنص على كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية وآجال استئنافها هي الواجبة التطبيق في قضايا التحفيظ العقاري بدلا من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية عملا بمبدأ تقديم النص الخاص على النص العام ".

[5] – قرار المجلس الأعلى عدد 1100 بتاريخ 1990/5/16 منشور بمجلة قضاء الملجلس الأعلى عدد 44 ص 18.

6- **النفاذ المعجل**: ينص الفصل 361 من ق.م.م على كون الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري، الأمر الذي يوحي بمفهوم المخالفة أن الأحكام الابتدائية تكون غير مشمولة بالنفاذ المعجل[1].

الفقرة الثانية: الإجراءات في المرحلة الاستئنافية

ينص الفصل 41 من ظهير ت ع على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية تكون دائما قابلة للاستئناف كيفما كانت قيمة التراع (العقار)، ويكون بوضع الطلب مرفوقا بنسخة من الحكم المطعون فيه إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية، حسب القواعد العامة المقررة في قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري.

وأنه طبقا للفصل 42 من ظهير التحفيظ، لا يلزم المستأنف بتقديم مقال الاستئناف وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م وإنما يتعين عليه فقط أن يقدم طلب الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت 9الحكم ولو كان خاليا من بعض البيانات المشار إليها في الفصل 142 م.م، مثل بيان أوجه وأسباب استئنافه ووسائل دفاعه، على أن يقدمها لاحقا أو بعد إنذاره من طرف المستشار المقرر (ف 42 من ظهير التحفيظ)، فإذا لم يدل بالبيانات المطلوبة منه رغم توصله بإشعار المستشار المقرر يحكم بعدم قبوله بعلة كونه مخالفا لمقتضيات الفصل 42 من ظهير التحفيظ وليس الفصل 142 م.م.

ويترتب عن الاستئناف في مادة التحفيظ أثر موقف للتنفيذ، وأثر ناقل:

---

[1] – عبد العلي العبودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1983، ص 49.

فأما الأثر الموقف للتنفيذ، يتجلى في كون الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأن كل إجراء من إجراءات التنفيذ إذا حصل، رغم استئناف الحكم الذي تم تنفيذه قد يعرض صاحبه للحكم عليه بتعويضات لصالح المستأنف[1].

وأما الأثر الناقل، فيعني أن الاستئناف ينقل مجموع النزاع بجميع أسسه الواقعية والقانونية التي كانت معروضة في المرحلة الابتدائية، ويطرحه أمام محكمة الاستئناف كدرجة ثانية لتعيد فيه النظر من جديد، وكأنما تنظر القضية ابتدائيا، لذلك منح المشرع للمستشار المقرر لدى محكمة الاستئناف اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتحقيق في موضوع النزاع من جديد[2].

ويطرح الإشكال في هذا الصدد بالنسبة للمسطرة أمام محكمة الاستئناف، فهل تطبق قواعد المسطرة الشفوية أم المسطرة كتابية؟

يرى بعض الفقه[3] أن قواعد المسطرة الواردة في ظهير التحفيظ، لا تلغي قواعد المسطرة المدنية غير المخالفة، بل تبقي عليها، ويتعين تطبيقها في قضايا التحفيظ، أي تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية (ف45 و329 م.م) كقانون عام، عند غياب المقتضى القانوني في ظهير التحفيظ العقاري.

---

[1] – للإشارة فإن التنفيذ في قضايا التحفيظ على الملكية العقارية، وليس المحكمة كما هو عليه الأمر في القضايا العادية، وإن درج العمل تضمين الأحكام بفقرة نشير إلى أن المحكمة تتول تنفيذ الحكم الذي أصدرته.

[2] – د. محمد خيري: الملكية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، م.س، ص 319–320.

[3] – حكم عدد 17229 صفر 1388 (15 ماي 1968)، مجلة القضاء والقانون، عدد 93 ذكره الدكتور محمد خيري، م.س، ص 307.

غير أن اجتهاد المجلس الأعلى ذهب خلاف ذلك معتبرا أن مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة، وهو ما يستفاد من قرار له بتاريخ 27 أكتوبر 1977 حيث جاء فيه: "إن الظهير المطبق على العقارات المحفظة لا يشترط أي شكل معين للتبليغ، كما أنه لا يحيل على قواعد المسطرة المدنية في ذلك"[1].

والجدير بالذكر أن تنصيب المحامي ليس إلزاميا في قضايا التحفيظ العقاري، فللخصوم مباشرة المسطرة شخصيا في قضاياهم والدفاع فيها بأنفسهم دون إجبارهم على تنصيب المحامي[2].

كما أن حسن سير العدالة يقضي بضرورة إضافة لملفات النزاعات بعضها إلى بعض إذا تعلقت بعقار واحد لتسري عليها المسطرة في آن واحد وثبت فيها نسب المحكمة المعروض عليها النزاع، ويتم ضمنها إما تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم.

الفقرة الثالثة: خصوصية الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ

تجدر الإشارة إلى أن قرارات محكمة الاستئناف كانت في الأصل نهائية، ولا تقبل أي طعن إلا ان من طرف النيابة العامة ولمصلحة القانون منذ سنة 1913، ونظرا لإحداث المجلس الأعلى في شتنبر 1957 ، كان لزاما على المشرع أن يتدخل لتعديل الفصل 47 من ظهير التحفيظ بواسطة ظهير 28 ماي 1958 وبالتالي السماح بالطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف.

---

[1] – ذكره محمد خيري، م.س، ص 309. وجاء في قرار حديث رقم 132، بتاريخ 17 أبريل 1981 ما يلي: "لا يطبق ق.م.م في قضايا التحفيظ العقاري إلا في الحالات التي تحيل عليها قانون التحفيظ"، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 28، ص 181.

[2] – د.عبد العلي العبودي: م.س، ص 34.

غير أن الفصل 47 من ظهير التحفيظ، اكتفى بالإشارة إلى حق الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، دون أن يحدد مسطرة خاصة بذلك، مثل ما هو عليه الأمر في المرحلة الابتدائية الاستئنافية.

لهذا فإن مسطرة الطعن في قضايا التحفيظ العقاري ستكون تطبيقا من تطبيقات القواعد العامة، ومع ذلك فإن النصوص المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى جاءت بخصوصيات تهم قضايا التحفيظ العقاري، خاصة منها ما يتعلق بأجل الطعن بالنقض، وآثاره، والتنفيذ.

1- آجال الطعن بالنقض:

إن أجل النقض في قضايا التحفيظ العقاري محدد بشهرين[1] طبقا للفصل 47 خلافا لما هو عليه الأمر في القضايا الأخرى، حيث حدد المشرع شهرا واحدا للطعن لدى المجلس الأعلى، ويعتبر هذا الأجل من أهم خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري.

وقد كرس المجلس الأعلى القاعدة المنصوص عليها معتبرا أنه: "لما كان الفصل 358 م.م ينص على أن أجل الطعن بالنقض هو 30 يوما ما لم توجد مقتضيات خاصة، فإن الفصل 47 من ظهير مسطرة التحفيظ يعد من تلك المقتضيات الخاصة التي تنص على أجل خاص للطعن بالنقض هو شهران من تاريخ التبليغ لا 30 يوما"[2].

---

[1] - ينص الفصل 47 الآنف الذكر في فقرته الأخيرة على ما يلي:
" إن الأحكام يجب تبليغها بنصها الكامل إلى جميع الأطراف في عناوينهم الحقيقية أو المختارة".
وهذا المقتضى التشريعي مخالف لما يقضي به الفصل 358 م.م الذي استبعد العنوان المختار أثناء تبليغ الأحكام.

[2] - قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1982/4/16، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 31.

2- آثار الطعن بالنقض:

إن الطعن بالنقض لا يترتب عليه عموما أي أثر موقف للتنفيذ كقاعدة عامة، فالطرف الذي صدر الحكم لصالحه، له الحق في سلوك إجراءات تنفيذه فورا ولو أدى ذلك التنفيذ إلى نتائج غير قابلة للإصلاح.

غير أن الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ العقاري له أثر موقف للتنفيذ .بمقتضى الفصل 361 من ق م م، ولا يتأتى لأي طرف طلب تنفيذ الحكم إلا بعدما يصدر المجلس الأعلى قراره في الحكم المطعون فيه، ويستتبع ذلك أن كل تنفيذ من طرف المحافظ في مثل هذه الحالات، يعتبر لاغيا ولا قيمة له[1].

3- تنفيذ الأحكام:

حينما تنتهي الآجال المقررة للاستئناف أو الطعن لدى المجلس الأعلى دون أن يتقدم أي طرف بالطعن رغم التبليغ الحاصل لهم في موطنهم الحقيقي أو المختار، فيجب على المحكمة المعنية بالأمر أن تعمل بالمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2/37 من ظهير التحفيظ العقاري، أي إحالة الأطراف على المحافظ العقاري مع بعث نسخة من الحكم الصادر في الموضوع قصد التنفيذ، علما أن هذا الحكم يوكل أمر تنفيذه تلقائيا للمحافظ العقاري ولا تطبق بشأنه مسطرة التنفيذ المقررة في قانون المسطرة المدنية، أي أنه لا وجود للنسخة تنفيذية، وشهادة عدم الطعن، وفتح ملف التنفيذ كما هو الشأن بالنسبة لإجراءات التنفيذ في القضايا الأخرى[2].

---

[1] - د. محمد خيري: م.س، ص 341-342.

[2] - د. محمد خيري، م.س، ص 350.

الفقرة الثانية: خصوصيات تتعلق بالطعن في قرارات المحافظ

أولا: قرارات المحافظ بشأن مطلب التحفيظ

إن للمحافظ صلاحية كاملة لقبول أو رفض وإلغاء كل مطلب تحفيظ يقدم إليه، فمتى توافرت جميع الشروط في المطلب، فإن المحافظ يصدر قراراً بقبول طلب التحفيظ، غير أن الإشكال يثار إذا قرر المحافظ رفض أو إلغاء مطلب التحفيظ.

هذا وإن حالات الرفض تكون غالبا عند عدم توفر الطلب على الشروط المطلوبة عند تقديم المطلب، أما حالات الإلغاء وهي الكثيرة فإنها يأتي بعد تسجيل مطلب التحفيظ ثم يحدث مبرر يسمح بالإلغاء، كما لو تغيب طلب التحفيظ عن حضور عملية التحديد لموقت، (ف 22و23 من ظهير رمضان)، أو تماطل في إجراء ومتابعة المسطرة بعد إنذاره من طرف المحافظ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل (ف 50 من ظهير التحفيظ). هذا إضافة على حالة الإلغاء لعدم كفاية الحجج والوثائق المدلى بها تأييدا للمطلب (ف 38 من ظهير 9 رمضان).

وينص الفصل 96 من ظهير 9 رمضان على أنه: "في حالة ما إذا رفض المحافظ أن عقارا كلا أو بعضا أو يسجل حقا عينيا او يشطب عليه بالسجلات العقارية، فإن قراره يجب ان يكون معللا، وان يبلغ لطالب التحفيظ بدون تأخير".

وإذا كان تعليل المحافظ مبنيا على حكم قضائي، فإنه لا تثار صعوبة في وجه المحافظ، حيث يكتفي بالإشارة إلى هذا الحكم، أما تعليل رفض التحفيظ في الحالات الأخرى، ينبغي أن يكون واضحا ومبنيا على أساس بحيث يخضع للطعن لدى القضاء الذي يبسط رقابته على مشروعية الأسباب المعتمدة في الرفض.

ثانيا: قرارات المحافظ بشأن التعرض

إن قرار المحافظ القاضي بقبول التعرض لا يتصور الطعن فيه[1]، لأن قراره هذا لا يفيد إثبات الحقوق المدعى بها من طرف المتعرض أو نفيها، ولكنه يفيد وجود نزاع بشأن العقار وبالحق موضوع مطلب التحفيظ، وقبول التعرض يتوقف على توفر الطلب على كافة الشروط الشكلية والجوهرية المفروضة قانونا، والطعن في قرارات المحافظ بشأن التعرض لا يكون إلا في حالة إلغائه أو رفضه.

وهكذا فإن قرار المحافظ برفض التعرض المقدم خارج الأجل المحدد في الشهرين من تاريخ نشر الإعلان بانتهاء التحفيظ المؤقت في الجريدة الرسمية (ف23 من ظهير 9 رمضان) هو قرار إداري يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

وبالمقابل، فإن قرار المحافظ بإلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية رغم إنذار المتعرض من طرف المحافظ، يصدر بصفة نهائية ولا يقبل الطعن.

---

[1] - والجدير بالذكر بالإشارة أن قرارات المحافظ غير النهائية، قد منح المشرع بشأنها إمكانية الطعن أمام المحكمة، وكذا أمام المحافظ العام للملكية العقارية، هذه الازدواجية في طرق الطعن يمكن أن تثير بعض الإشكالات، بمعنى انه هل يمكن الجمع بين الطريقتين في نفس الوقت؟ مع قد يترتب على ذلك من صدور قرارات متناقضة من طرف كل من المحافظ العام والمحكمة، لأن صلاحية المحافظ العام تخول له طلب أي ملف للتحفيظ قصد البحث واتخاذ قرار بشأنه، وللمحكمة بدورها صلاحيات البت في قرارات المحافظ، ويقول الدكتور محمد خيري جواب على هذا السؤال: "إن إزالة هذا التناقض يكمن في اتباع طريق واحد دون الآخر" وعلى المعني بالأمر أن يختار اللجوء إلى المحكمة أو إلى المحافظ العام، وفي لجوئه على المحكمة ضمانات أكثر لأنه يمنح لطالب التحفيظ أو المتعرض اتباع طرق الطعن حتى نهايتها.

غير إن إلغاء التعرض لعدم تقديم طالب التحفيظ للوثائق والمستندات المؤيدة له، يقبل الطعن استئنافا لدى المحكمة الابتدائية، إذا ما كان قرار الإلغاء هذا غير معلل، لهذا فإن المحافظين غالبا ما يعمدون إلى قبول التعرض نظرا لصعوبة تعليل الإلغاء في هذه الحالة.

هذه الصعوبة لا تطرح في الحالة التي يستند فيها التعرض على حكم قضائي قضى برفض التعرض، شريطة أن يكون هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن إما لفوات الأجل، أو لاستنفاذه جميع هذه الطرق.

وفي حالة تحرير محضر بالتصالح سواء تم ذلك بمبادرة من المحافظ أو من طالب التحفيظ أو المتعرض او أحدا من الغير، فإن هذا المحضر لا تكون له صبغة ورقة رسمية، وإنما يكون قوة الالتزام العرفي، ومع ذلك لا يجوز الطعن في صحة ما ورد بالمحضر إلا عن طريق دعوى الزور او أحد من أسباب الإبطال كنقص الأهلية أو عيوب الرضى من غلط وتدليس وإكراه وغبن إذا توافرت شروطها.